

1500032-85.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Gisele de Castro Catapano

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... DO INCISO III DO ART. 105 DA CF/88). CRIME DE ROUBO: MOMENTO DE CONSUMAÇÃO. É firme a jurisprudência desta colenda Corte de que o delito de roubo se consuma no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel subtraída mediante grave ameaça ou violência. Noutros termos: é de se considerar consumado o roubo, quando o agente, cessada a violência ou a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, 06110-100, Osasco, SP

Fone: (11) 2838-7557 - E-mail: osasco1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: 13h00min às 18h00min

Processo Digital 1500032-85.2022.8.26.0542 | Sentença | lauda 0 de 0
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500032-85.2022.8.26.0542

Controle: 2022/000029

Autor:

Justiça Pública

Acusado:

WILDE DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gisele de Castro Catapano

Vistos,

WILDE DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado por incurso nas penas do artigo 157, caput, e artigo 307, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, em 3 de janeiro de 2022, por volta das 15h45min, na Praça Dicran Echrefian, 69, Presidente Altino, nesta Cidade e Comarca de Osasco-SP, subtraiu para si, mediante grave ameaça contra Berdiane, uma peça de picanha Friboi, avaliada em R\$ 143,30 e pertencente à empresa-vítima Dia Brasil Sociedade Ltda., bem como, pouco tempo depois, na Rua Armênia, 428, Presidente Altino, nesta Cidade e Comarca de Osasco-SP, atribuiu-se, em proveito próprio, falsa identidade, para obtenção de vantagem.

Apurou-se que Wilde adentrou ao estabelecimento-vítima, na Praça Dicran Echrefian, 69, Presidente Altino, Osasco-SP, e pegou a peça de picanha, bem como um pacote de salsichas. Dirigiu-se ao caixa e, atendido por Berdiane, pagou apenas pela

salsicha, dizendo que não pagaria pela picanha. Quando seria abordado por funcionários do estabelecimento-comercial, Wilde anunciou o assalto, fazendo menção de estar armado com uma faca.

Wilde disse, em voz alta, que sairia dali sem pagar pela picanha e assim o fez, evadindo-se correndo.

Ocorre que a polícia foi acionada, sendo informadas as características físicas e vestimentas de Wilde, sendo ele localizado na Rua Armênia, 428, Presidente Altino, Osasco-SP.

Indagado, Wilde prontamente confirmou a prática delitiva, mas se apresentou aos policiais como Wilton dos Santos (R.G. 23.293.309/SP), constatando-se, posteriormente, serem os dados do irmão dele.

Conduzido à Delegacia de Polícia, Wilde foi reconhecido pelos funcionários da empresa-vítima como o autor do delito.

A denúncia foi recebida em 24 de janeiro de 2022 (fls. 101/103) e citado Wilde (fls. 111). Sobreveio a resposta escrita (fls. 118) e, não havendo causas de sumária absolvição, o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 119/120).

Em instrução processual criminal foram ouvidas as vítimas (fls. 161/163) e testemunhas (fls. 164/165), prosseguindo-se com o interrogatório do acusado (fls. 166).

Encerrada a instrutória, na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, nada foi requerido, sendo os debates orais convertidos em memoriais escritos (fls. 167). Em sede de memoriais escritos, o Dr. Promotor de Justiça pleiteou pela procedência da ação penal e consequente condenação de Wilde nos da denúncia (fls. 170/180).

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição com fulcro no artigo 386, inciso III ou VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, pela desclassificação para o artigo 155, do Código Penal, com absolvição pela ocorrência de crime impossível ou, ainda, pela aplicação do Princípio da Insignificância, reconhecendo-se atípica a conduta, e, por fim, pela aplicação do artigo 14, do Código Penal (fls. 185/210). É o relatório.

Fundamento.

Decido.

Preliminarmente, declaro a nulidade do reconhecimento pessoal na fase policial.

O Superior Tribunal de Justiça, em sua mais moderna jurisprudência, estabeleceu que o reconhecimento extrajudicial, seja pessoal ou fotográfico, que não observe os ditames do artigo 226, do Código de Processo Penal, não serve de lastro para embasar a condenação, ainda que o reconhecimento seja confirmado judicialmente.

“Uma reflexão aprofundada sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, leva a concluir que, com efeito, o reconhecimento (fotográfico ou presencial) efetuado pela vítima, em sede inquisitorial, não constitui evidência segura da autoria do delito, dada a falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento, quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas que podem gerar “falsas memórias”, além da influência decorrente de fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor; o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.). 5. Diante da falibilidade da memória seja da vítima seja da testemunha de um delito, tanto o reconhecimento fotográfico quanto o reconhecimento presencial de pessoas efetuado em sede inquisitorial devem seguir os procedimentos descritos no art. 226 do CPP, de maneira a assegurar a melhor acuidade possível na identificação realizada. Tendo em conta a ressalva, contida no inciso II do art. 226 do CPP, a colocação de pessoas semelhantes ao lado do suspeito será feita sempre que possível, devendo a impossibilidade ser devidamente justificada, sob pena de invalidade do ato. 6. O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede

inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial (...) 8. Tendo a autoria do delito sido estabelecida com base unicamente em questionável reconhecimento fotográfico e pessoal feito pela vítima, deve o réu ser absolvido" (Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus 652.284-SC. Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Julgamento: 27 de abril de 2021).

Ora, no caso destes autos, tem-se que Berdiane, em Juízo, foi incapaz de descrever o agente, posto que tremia muito no momento do delito, e nem reconheceu qualquer das três pessoas apresentadas.

Ainda, do auto de reconhecimento extrajudicial não consta que teriam sido colocadas outras pessoas para fins de reconhecimento.

Edmilson, em Juízo, esclareceu que somente viu o roubador quando ele foi colocado na viatura. Igualmente, não consta do auto de reconhecimento extrajudicial que tenham sido colocadas outras pessoas para o ato de reconhecimento. Portanto, não observadas as cautelas do artigo 226, do Código de Processo Penal, uma vez que não apresentada nenhuma outra pessoa para fins de reconhecimento, tornando esse ato extrajudicial nulo. Observe-se, ainda, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a inobservância das regras para fins de reconhecimento na fase policial macula o reconhecimento em Juízo, eivado de preconceção da imagem da pessoa a ser reconhecida.

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO.

NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, conseqüentemente, causar erros judiciais de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis. 3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório. 4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato. 5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das conseqüências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a

jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciais e, conseqüentemente, de graves injustiças. 6. É de se exigir que as polícias judiciais (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua insita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a "defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis" (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia" (art. 129, II). 7. Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado. 8. Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo "processualmente admissível e válido" (Figueiredo Dias). 9. O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma observância do procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova produzida em seu desfavor. Ademais, as falhas e as inconsistências do suposto reconhecimento – sua altura é de 1,95 m e todos disseram que ele teria por volta de 1,70 m; estavam os assaltantes com o rosto parcialmente coberto; nada relacionado ao crime foi encontrado em seu poder e a autoridade policial nem sequer explicou como teria chegado à suspeita de que poderia ser ele um dos autores do roubo – ficam mais evidentes com as declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a possibilidade de reconhecimento do acusado. 10. Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser declarado absolutamente nulo, com sua conseqüente absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado. 11. Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito – conforme reconheceu o Magistrado sentenciante – emprestado o veículo usado pelos assaltantes para chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na posse dos objetos roubados, conduta que não pode ser tida como determinante para a prática do delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente houve tal empréstimo do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por parte da dupla que cometeu o roubo. É de se lhe reconhecer, assim, a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância). 12. Conclusões: 1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 13. Ordem concedida, para: a) com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o paciente Vânio da Silva Gazola

em relação à prática do delito objeto do Processo n. 0001199-22.2019.8.24.0075, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão - SC, ratificada a liminar anteriormente deferida, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso; b) reconhecer a causa geral de diminuição relativa à participação de menor importância no tocante ao paciente Igor Tártari Felácio, aplicá-la no patamar de 1/6 e, por conseguinte, reduzir a sua reprimenda para 4 anos, 5 meses e 9 dias de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Dê-se ciência da decisão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que façam conhecer da decisão os responsáveis por cada unidade policial de investigação" (Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus 598.886-SC. Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz. Julgamento: 13 de abril de 2021).

Assim sendo, com fulcro no artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal DECLARO NULA a PROVA consistente em RECONHECIMENTO PESSOAL EXTRAJUDICIAL e, por derivação, a PROVA do RECONHECIMENTO JUDICIAL (Supremo Tribunal Federal. R.H.C. 90.376. Relator: Ministro Celso de Mello. Julgamento: 2 de abril de 2007).

No mais, a materialidade delitiva se consubstancia em auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 11/13), auto de exibição, apreensão, avaliação e entrega (fls. 16/18), bem como pelos testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório (fls. 161/165) e, especialmente, pela confissão judicial de autoria de autoria no tocante a subtração da carne (fls. 166).

Perante a D. Autoridade Policial, Wilde se reservou no direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 6).

Em Juízo, afirmou que entrou no mercado e iria comprar uma salsicha. Fazia muito tempo que não sabia o que era comer carne e pegou a picanha na prateleira. Pensou que ninguém tinha visto e, quando foi pagar a salsicha, a moça disse: Você não vai pagar a picanha?. Ia devolver a picanha, mas juntou o segurança e outras pessoas para cima do interrogando. Acabou saindo correndo com a picanha. Havia três ou quatro pessoas em cima de si. Não fez menção que estava com arma. Não disse que estava com faca. Foi abordado 4min a 5min depois na segunda esquina do Supermercado Dia. Não informou o nome de seu irmão. Deu seu nome correto (fls. 150).

A parcial confissão de Wilde deve ser aceita naquilo que estiver amparada pelo conjunto probatório amealhado e afastada na esteira do que for contrariada, de acordo com a interpretação holística das provas.

A vítima Berdiane relatou que o autor entrou no mercado e a declarante ficou olhando. Ele passou pelo caixa e foi até o local onde pegou salsicha e picanha. Ficou observando se ele iria pagar. Quando ele se aproximou do caixa, pagou apenas a salsicha. Questionou o autor se ele iria pagar a picanha e ele disse que não iria pagar a picanha e que chamaria quem quisesse. Disse para ele que não iria levar a picanha. Ele retrucou dizendo que iria levar e que poderia chamar quem quisesse, simulando que estava armado com uma faca. Ele correu e, então, a declarante chamou um menino e, ajudados por um cliente, correram atrás dele. Ele entrou em um barzinho e, logo em seguida, a polícia chegou.

O acusado simulou que estava com a faca levantando a blusa um pouquinho e dizendo que estava armado com uma faca. Viu essa faca. Não sabe se os policiais tentaram localizar a faca e não sabe se acharam.

Esclareceu que ele pegou a salsicha e a picanha. Em cima do balcão de pagamento colocou apenas a salsicha e ficou segurando a picanha com a mão para baixo do balcão. Ele passou pelo caixa e a declarante o interpelou perguntando se não iria pagar a picanha. Foi aí que ele disse o que já se referiu. Quando o acusado simulou que estava com a faca, além da declarante, a menina do caixa e a encarregada do açougue viram. Tentaram pegar a picanha dele, mas foi aí que ele virou o braço dizendo que estava armado e que não iria entregar a picanha e que poderiam chamar quem quisesse. Ele correu e outro menino do estabelecimento chegou e correu atrás também. Foram gritando pega ladrão e um cliente conhecido que estava de carro também foi atrás dele.

Ainda, especificou ainda mais a dinâmica do momento da ameaça: pediram para que ele

devolvesse a picanha e ele disse que não iria dar. Neste momento estavam a declarante, a caixa e a encarregada do açougue. Tentaram puxar a picanha dele e ele informou que estava armado. O autor chegou a tirar a picanha da roupa, disse que iria levar, que não iria pagar e não teria quem o impedisse. Nesse momento que tentaram puxar a picanha ela estava nas mãos dele. O acusado correu praticamente o quarteirão inteiro ao redor do mercado.

Ele correu com a picanha e com a salsicha. Tudo foi recuperado. Isso foi recuperado dentro do bar. Não consegue descrever o autor porque tremia muito na hora.

Realizado reconhecimento, não teve condições de reconhecer nenhum dos três apresentados em audiência (fls. 161/162).

A vítima Edmilson narrou que estava saindo para o almoço e quando saiu do estabelecimento, Berdiane lhe acionou e disse que o autor tinha acabado de roubar o local e estava lhe ameaçando. Um cliente o seguiu de carro para um lado enquanto o declarante correu atrás dele, mas o perdeu de vista. Assim que dobrou a esquina, logo de frente já estava a viatura, sendo que os policiais abordaram o autor. Não viu o momento do crime. Só depois soube que o rapaz estaria armado, que não queria pagar a picanha e que poderiam chamar quem quisessem. Esteve na Delegacia e reconheceu o autor. Inclusive ele tinha passado o nome errado. Só viu a imagem de Wilde quando ele foi colocado na viatura. (fls. 163).

A testemunha Policial Militar Anderson asseverou que foram informados de um roubo no Supermercado Dia e colheram informações acerca do autor e sentido tomado. Foram no encalço dele. Cinco minutos depois localizaram e abordaram o acusado em poder da res furtiva. O acusado confirmou a subtração no Supermercado Dia e foi conduzido ao D.P.. Ele não portava documentos e colheram os dados através dele que informou os dados do irmão. Depois ele foi planilhado pelo I.I.R.G.D. e retornou a informação de que os dados eram do irmão.

Houve apreensão de uma peça de picanha. A picanha estava em uma mochila. A vítima relatou que no momento da subtração, ao ser questionado, o acusado fez menção de estar com uma faca. A faca não foi localizada. O acusado confirmou a subtração, mas não confirmou que estava com faca.

Ele não mencionou que outras pessoas chegaram quando ele estava pagando.

Acompanharam na Delegacia a vítima e testemunha. Eles não ouviram o que foi dito pelo acusado na abordagem (fls. 164).

A testemunha Policial Militar Rodrigo declinou que foram informados por populares acerca do roubo no Supermercado Dia próximo do local e fornecidas as características do autor saíram no encalço dele. Momentos após abordaram o acusado com uma bolsa que continha a peça de carne subtraída. Ele confessou a prática da subtração (fls. 165).

A autoria é, pois, indelegável. Inclusive por ter sido Wilde abordado com a res e confirmado que foi ele quem pegou a picanha. Neste sentido:

“Nos delitos patrimoniais como o furto, a apreensão da res em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e inverte o ônus da prova, impondo-lhe justificativa inequívoca, de modo que aquela que se mostra dúbia e inverossímil transmuda a presunção da certeza, autorizando o desate condenatório” (Ap. no 646.631, 4ª Câ. - Rel. Juiz Passos Freitas, j. 27.07.93, V.U., rolo-flash 750/236).

Não há que se cogitar da existência da grave ameaça perpetrada pelo acusado. Isso porque a vítima narrou que foi abordada, sendo que o agente estava com a mão para baixo, simulando que estava armado e dizendo que portava a faca.

Tentativa, à evidência, não ocorreu. A questão do momento da consumação do crime de roubo hoje se encontra devidamente pacificada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Não é necessária a posse tranquila da coisa roubada pelo roubador, operando-se a consumação quando detém a posse, ou seja, com a retirada da coisa que estava em poder da vítima com o emprego de grave ameaça ou violência, independentemente de locupletar-se ou não depois disso. Não é, pois, necessária a posse tranquila da res, fora da esfera de vigilância do dominus.

O roubo está consumado no instante em que o agente se torna, mesmo que por pouco tempo, possuidor da res subtraída mediante grave ameaça. A rápida recuperação da coisa e a prisão dos agentes não caracteriza a tentativa (S.T.J. - R.E. 77.868 - SP

- Rel. Min. Félix Fischer- J. 04.03.97- DJU 14.04.97). Tal é o entendimento, inclusive, do Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CABIMENTO (ALÍNEA "C" DO INCISO III DO ART. 105 DA CF/88). CRIME DE ROUBO: MOMENTO DE CONSUMAÇÃO. É firme a jurisprudência desta colenda Corte de que o delito de roubo se consuma no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel subtraída mediante grave ameaça ou violência. Noutros termos: é de se considerar consumado o roubo, quando o agente, cessada a violência ou a grave ameaça, inverte a posse da res furtiva. Sendo desnecessário que a posse da coisa seja mansa e pacífica. Precedentes: RE 102.490, Relator o Ministro Moreira Alves (Pleno); HC 89.958, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence (Primeira Turma); HC 89.653, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (Primeira Turma); e HC 89.619, de minha relatoria (Primeira Turma). Por outra volta, não procedem as alegações de que houve reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ) e que não ficou demonstrada a divergência de interpretação, exigida pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da CF/88. Habeas corpus indeferido" (HC 89959, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2007, DJe-087 DIVULG 23-08-2007 PUBLIC 24-08-2007 DJ 24-08-2007 PP-00070 EMENT VOL-02286-04 PP-00662 RT v. 96, n. 866, 2007, p. 565-569).

Não há qualquer viabilidade de desclassificação para o delito de furto. Do conjunto probatório amealhado aos autos, verificou-se a caracterização da grave ameaça, mediante simulação de faca, quando da subtração. Tem-se que este elemento tipifica o crime em tela, ou seja, o roubo, cuja característica fundamental é a redução da vítima à impossibilidade de resistir pelo caráter intimidativo da grave ameaça. Outrossim, não há que se falar em crime impossível, pela existência de sistema de vigilância, aplicando-se, por analogia, a Súmula 567, do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Ainda mais em se tratando de roubo e não furto.

É inaplicável o Princípio da Insignificância, tratando-se de delito cometido mediante grave ameaça, conforme pacífica jurisprudência, notadamente o Habeas Corpus 111.195, do Supremo Tribunal Federal.

Quanto ao artigo 307, do Código Penal, verifica-se que Wilde se identificou falsamente, afirmando ser seu irmão, Wilton.

Cleber Masson, sobre o artigo 307, do Código Penal, ensina que:

"É "atribuir", no sentido de imputar a si próprio ou a terceiro falsa identidade. Essa conduta abrange as seguintes hipóteses: a) O agente atribui a si próprio ou a terceiro a identidade de outra pessoa, efetivamente existente. Opera-se a substituição de pessoas; e b) O agente atribui a si próprio ou a terceiro identidade fictícia (imaginária, inexistente), como no caso daquele que se identifica como o protagonista de uma novela. Cuida-se de crime de forma livre, compatível com os mais diversos meios de execução. Embora seja mais comum a realização da falsa identidade oralmente, também se admite a prática por escrito (exemplo: o agente preenche um formulário se passando por terceira pessoa), por gestos (exemplo: durante a missa, o padre pergunta quem foi a pessoa responsável por vultosa doação a moradores de rua, e alguém falsamente levanta a mão para ganhar prestígio na sociedade) etc" (MASSON, Cleber: Código Penal Comentado, 2ª Ed. Rev., Atual. e Ampl. - São Paulo: MÉTODO, 2014. P. 1.077).

No caso vertente, tem-se que Wilton se identificou como outra pessoa, ou seja, atribuiu a ele mesmo identidade de outrem, existente, quando abordado pela Polícia Militar.

Realizada a figura penal típica, não há que se falar em absolvição, até por ter Wilde agido com o dolo típico caracterizador, buscando vantagem que pode ser de qualquer natureza. E mais, o delito atingiu a consumação, em se tratando de crime formal, consumando-se com a simples atribuição de falsa identidade.

Entre os delitos de roubo e falsa identidade houve mais de uma ação, para mais de um crime, com desígnios autônomos, satisfazendo, portanto, o concurso material, nos termos do artigo 69, do Código Penal. Nesse sentido:

"PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO E EXTORSÃO. CONDUTAS DIVERSAS. CONCURSO MATERIAL.

SÚMULA 96/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE, MOTIVOS E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO MERAMENTE MATEMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. A conduta do agente, consistente em subtrair bens pertencentes à vítima mediante grave ameaça e, ainda, em exigir a entrega do cartão bancário e senha, embora realizada no mesmo contexto, caracteriza, de forma autônoma, os delitos de roubo e de extorsão. Precedentes. 2. A afirmação da Corte a quo de que não se chegou a realizar a retirada de dinheiro em caixa eletrônico, com o uso da senha da vítima, é irrelevante para a configuração do crime de extorsão, nos termos da Súmula 96/STJ. 3. A existência de vontade direta e livre, quando da prática do crime, bem como a sua gravidade abstrata não são argumentos idôneos a justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, com base na valoração negativa da culpabilidade. Precedentes. 4. Por se tratar de elementar do delito, a busca pelo lucro fácil não é apta para agravar a pena. Precedentes. 5. Quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado "normal à espécie", não há falar em consideração desfavorável ao acusado. Precedentes. 6. Ostentando o acusado mais de uma condenação anterior definitiva, é possível a utilização de parte delas na primeira etapa da dosimetria, para caracterizar os maus antecedentes, e de outra para valorar negativamente a personalidade, sem que isso implique a ocorrência de bis in idem. Precedente. 7. Deve ser mantida a valoração negativa a título de consequências do crime, uma vez que foi utilizada fundamentação que desborda da figura típica do delito. 8. Na segunda fase da dosimetria, uma vez reconhecida pelo Tribunal de origem a atenuante da confissão espontânea, impõe-se, conforme pacificado entendimento desta Corte (EResp n. 1.154.752/RS, da minha relatoria, DJe 4/9/2012), a sua compensação com a agravante da reincidência. 9. Não se admite, no crime de extorsão, com base em critério puramente aritmético, a aplicação de fração de aumento superior à mínima. Precedente. 10. Recurso especial parcialmente provido. Habeas corpus concedido de ofício" (REsp 1255559/DF - RECURSO ESPECIAL 2011/0128166-0 - Relator(a) Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR (1148) - Órgão Julgador T6 - SEXTA - Data do Julgamento 11/06/2013 - Data da Publicação/Fonte DJe 25/06/2013) Conclui-se, pois, pela procedência da ação penal, restando tipificado os delitos previstos no artigo 157, caput, e artigo 307, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

O acusado não agiu com intensidade dolosa anormal para os delitos da espécie que justifique a exacerbação da pena-base acima do mínimo legal, conforme permissão do artigo 59, do Código Penal.

Wilde faz jus à atenuante do artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, para o artigo 157, do Código Penal. Entretanto, como é cediço, ao Magistrado não é dado transgredir os limites que a lei fixa para as penas, salvo nos casos em que tal faculdade é expressamente outorgada. Assim, inadmissível é a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, ainda quando se cuide de agente confesso judicialmente: "Na aplicação da pena, as circunstâncias atenuantes, de consideração obrigatória, não permitem a fixação da reprimenda em parâmetros inferiores ao mínimo legal, não havendo confundi-las com as causas de diminuição de pena, que, estas sim, ensejam essa possibilidade". (RJD 23/299)

É de se observar que a Súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça não revogou sua Súmula 231. A atenuante do artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal continua não tendo o condão de reduzir a reprimenda para abaixo do mínimo legal. Neste sentido, inclusive, já decidiu o próprio Superior Tribunal de Justiça: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA VALORADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. SÚMULA 545/STJ. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE SEM REFLEXOS NA PENA. SÚMULA 231/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da

impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - De acordo com o enunciado n. 545/STJ, "Quando a confissão for utilizada para formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal". III - In casu, a forma da confissão da paciente, para se beneficiar de tese da defesa, configura confissão qualificada, de modo que foi expressamente confirmado pelo juiz de origem que a paciente admitiu a imputação dos fatos relativos ao dia 06/01/2016. IV - Destarte, considerando a utilização da confissão para formara convicção do julgador, deve ela ser apreciada como circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria da pena. Entretanto, considerando que a pena-base da paciente foi fixada no mínimo legal, "[n]os termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (AgRg no AREsp n. 623.682/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 19/10/2015). Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão na dosimetria, sem reflexos na pena definitiva (Súmula 231 STJ), mantidos os demais termos da condenação" (Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus 431.336-RS. Relator: Ministro Felix Fischer. Julgamento: 12 de junho, 2018. Publicação: 15 de julho, 2018).

Wilde é reincidente, ex vi da informação trazida pela certidão criminal de fls. 29/44 dando conta de anterior condenação sem que tenha havido o transcurso do quinquênio depurador. Assim, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal, a reprimenda será exasperada em 1/6.

Considerando os elementos acima e os demais parâmetros contidos no artigo 59, do Código Penal:

artigo 157, caput, do Código Penal: fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Deixo de agravar a reprimenda pela incidência do artigo 61, inciso I, do Código Penal, compensando-o com o artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Não há outras atenuantes ou agravantes. Não há causas de aumento ou de diminuição;

artigo 307, do Código Penal: fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 10 (dez) dias-multa, calculados na base. Não há atenuantes, nem aquela prevista pelo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, posto que Wilde explicitamente negou a prática delitiva. Pela incidência do artigo 61, inciso I, do Código Penal, exaspero a reprimenda em 1/6, totalizando 11 (onze) dias-multa, calculados em seu patamar mínimo. Não há outras atenuantes ou agravantes. Não há causas de aumento ou de diminuição.

À míngua de qualquer outra causa legal de alteração, torno estas definitivas.